

0000576-93.2022.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Latrocínio

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/12/2022

... do roubo era o pagamento de dívida de tráfico, (m) a arma de fogo era de sua namorada.

Conforme dito alhures, a autoria está igualmente demonstrada. As vítimas já haviam reconhecido o acusado em sede policial - ainda que por imagens -, e novamente identificaram o acusado como um dos indivíduos que os abordaram e cometeram os delitos ora imputados. Ainda, o próprio réu confessou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá-SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000576-93.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000576-93.2022.8.26.0366

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2175986/2021 - DEL.POL.MONGAGUA, 13312735 - DEL.POL.MONGAGUA, 1371/21/207 - DEL.POL.MONGAGUA, 2175986 - DEL.POL.MONGAGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN DE FRANÇA SILVA AGUIAR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de MARCOS HENRIQUE GUIMARÃES CARVALHO e RYAN DE FRANÇA SILVA AGUIAR na qual lhes imputa a prática de infração penal, por duas vezes, à luz do artigo 157, parágrafo 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, em concurso formal, nos termos do artigo 70, todos do Código Penal, assim como em face de GABRIELLY DA SILVA, na qual lhe imputa a prática da infração penal contida no artigo 157, parágrafo 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Narra-se na denúncia que “no dia 27 de junho de 2021, por volta das 14h03, na Rua Honduras, n. 386, Vila Vera Cruz, nesta cidade e comarca de Mongaguá, Marcos e Ryan, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito comum, o automóvel marca/modelo Ford Ranger, placa GDW9877, ano 2017, pertencentes às vítimas José Vitoriano Uchôa, sendo certo que da violência empregada, somente não resultou óbito da vítima José por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Gabrielly concorreu, prestando auxílio material, para a prática do delito acima descrito.”

A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2021 (fls. 203/205). Na mesma oportunidade, decretada a prisão preventiva de Marcos Henrique Guimarães Carvalho e Ryan de França Silva Aguiar.

O feito foi desmembrado em relação ao acusado Ryan de França Silva Aguiar (fls. 251/252).

Devidamente citado (fls. 370), o acusado Ryan apresentou resposta à acusação (fls. 382/387).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (fls. 331/333), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório (fls. 418/419 e fls. 446/447). Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais escritas (fls. 451/458), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa técnica apresentou alegações finais escritas (fls. 255/276). Em síntese, alegou a tese de desistência voluntária e requereu a aplicação de atenuantes à pena do acusado.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual veiculada imputação da prática do crime descrito no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por duas vezes, em concurso formal, nos termos do artigo 70, todos do Código Penal.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelo boletim de ocorrência (fls. 16/19), pelo relatório final das investigações (fls. 189/199), laudos periciais de corpo de delito (fls. 243/244 e fls. 245/246) e laudo pericial investigativo (fls. 253/287).

Quanto à autoria, houve o reconhecimento do acusado como um dos autores dos fatos ainda na fase policial pelas vítimas (fls. 129/130). Os depoimentos prestados pelas vítimas, testemunhas e o próprio interrogatório, a seguir colacionados, demonstram a certeza quanto à autoria de Ryan de França Silva Aguiar.

A vítima José Vitoriano Uchôa, ouvido em Juízo, relatou que (a) estava fechando o último cadeado do portão da casa de veraneio, agachado inicialmente, (b) sentiu uma

pessoa dando uma grava nele, até achou que era brincadeira, mas o sujeito estava pedindo as chaves do carro, (c) conseguiu se desvencilhar da grava e o sujeito começou a bater com a coronha do revólver, ficando cheio de sangue no rosto, (d) depois, escutou o grito de sua mulher, pois ele [o assaltante] tentou entrar pela porta do motorista do carro, ela se assustou e saiu do carro, momento em que o assaltante deu um tiro na perna dela, voltando a agredir o declarante, (e) com a adrenalina do momento, não sabia onde estavam as chaves. Então, voltou ao carro para ver se as chaves estavam lá, mas não estava, (f) ato contínuo, voltou-se novamente para a vítima José, já com a arma engatilhada, e deu um disparo contra ele, (g) foi o mesmo indivíduo que lhe deu as coronhadas que realizou o disparo, (h) pelo que percebeu, somente ele estava armado, o outro ficava agitando, mandando o comparsa atirar, (i) quando levou o tiro, ainda tinha forças, chamou a mulher para irem ao pronto socorro, (j) na esposa, a bala entrou e saiu e nele, não conseguiram detectar, sendo enviado para o hospital de Itanhaém, (k) o sujeito deu um disparo na mulher, depois um tiro no chão e, por fim, um tiro na vítima, à queima roupa, (l) não levaram o carro e após que recuperou do susto, percebeu que as chaves do carro estavam em seu bolso, (m) sentiu falta de seu celular, acreditando que os assaltantes o levaram, (n) demorou 08 dias para sair do hospital, (o) ainda hoje em dia sente um formigamento, mas em relação à operação, nada a relatar. Por fim, reconheceu o acusado Ryan como aquele que realizou o disparo contra si.

A vítima Maria da Conceição Uchôa, ouvida em Juízo, relatou que (a) saiu de dentro de casa, pegou os cachorros e colocou dentro do carro, estava mexendo na bolsa quando tudo aconteceu, (b) ouviu um barulho, olhou para o lado e viu um rapaz pegado no ombro de seu marido e lhe dando coronhadas na cabeça, (c) após, viu uma outra pessoa, que passou as mãos no painel do carro, momento em que percebeu se tratar de um assalto, (d) saiu do carro e, nesse momento, de costas, recebeu um tiro e encostou no muro, (e) depois ouviu outro tiro, que acertou na barriga de seu marido, (f) quando chegaram pessoas que estavam nas redondezas, os assaltantes, dois indivíduos, correram, (g) o rapaz que estava com o revólver estava com um boné e o outro ficava encostada na caminhonete gritando para atirar logo, (h) com a fuga dos criminosos, conseguiram correr para o pronto socorro, (i) os bandidos correram para o lado de um bar, levaram o celular do marido, (j) não precisou de cirurgia, mas tomou pontos, (k) o marido ficou internado e passou por cirurgias, (l) não têm sequelas graves, mas apresenta uma cicatriz e sente “uma queimadura” no local do ferimento, (m) psicologicamente, tem muito medo, não quer mais ir à praia, não consegue dormir, nem quer saber daquela casa na praia, (n) o réu foi o sujeito que estava com a arma e realizou os disparos. Por fim, reconheceu o acusado Ryan como aquele que realizou o disparo contra si.

A testemunha Roberto Gomes, policial civil, ouvido em Juízo, disse que (a) juntamente com o policial Alexandre, ficaram sabendo que na data anterior ocorreu um crime contra um casal de senhores, em que foram alvejados com arma de fogo, (b) a mulher foi liberada e o senhor teve que ficar internado no hospital, (c) nas investigações, concluíram que o crime foi realizado por dois rapazes e uma moça, (d) apuraram que os assaltantes passaram por duas ou três vezes na frente da casa e ficaram em um bar na esquina aguardando, (e) quando o casal saiu em uma caminhonete, eles realizaram a abordagem, (f) com as investigações, descobriram que o crime foi praticado por um indivíduo chamado Marcos e outro Ryan, (g) Gabrielly, a terceira participante, disse que foi para Mongaguá a convite de Ryan, supostamente para ir na casa de uma tia. Por fim, reconheceu o réu como um dos indivíduos que participou do crime.

A testemunha Ricardo Fogaça de Oliveira, policial militar, em Juízo, relatou que (a) na data dos fatos, a equipe foi acionada via COPOM para atender ocorrência de vítimas alvejadas com arma de fogo, (b) apurou-se que as vítimas já haviam sido atendidas no hospital, tendo eles se dirigido até a unidade de atendimento, (c) Sr. José relatou que estava de saída de sua casa de verão, momento em que dois sujeitos

o abordaram exigindo as chaves do carro, sendo agredido com coronhadas, posteriormente foi efetuado um disparo na perna de sua esposa e outro em seu abdômen.

A testemunha Tibúrcio Augusto de Barros, em Juízo, disse que (a) atendeu os assaltantes em seu estabelecimento comercial, cerca de 60 metros do local do crime, (b) eram dois rapazes e uma moça, (c) o ocorrido mesmo, não viu, apenas ouviu os disparos, (d) o estabelecimento dele é próximo do local das vítimas, (e) não conseguiu ouvir a conversa que os indivíduos tiveram dentro de seu estabelecimento, pois falavam muito baixo entre eles.

A testemunha Gilson Guimarães Santos, em Juízo, narrou que (a) é motorista de Uber/99 Táxi, (b) por volta das 13h10, recebeu uma chamada da corré, que saiu correndo até o encontro do motorista e permaneceu abaixada no carro, durante todo o trajeto, (c) foi chamado na delegacia para prestar depoimento, tendo reconhecido a passageira.

Em seu interrogatório, o acusado Ryan de França Silva Aguiar disse que (a) os fatos narrados são verdadeiros, mas nem tudo, (b) morava com sua namorada na Praia Grande, e ela chegou com uma quantidade de droga, tendo eles usado o entorpecente, (c) depois que terminaram de usar, ela disse que precisavam pagar as drogas, porque o traficante estava ameaçando ela de morte, (d) como não tinham como pagar, ela sugeriu que fossem até Mongaguá cometer roubo, (e) como estavam no efeito da droga, aceitou realizar o roubo, tendo chamado Marcos para acompanhá-los, (f) foram até o local, chegaram em um bar, pediram uma cerveja e alguma coisa para comer, (g) escolheram a melhor oportunidade e foram até esse casal que estava saindo da garagem, (h) estava em punho da arma de fogo, tendo a colocado nas costas da vítima, (i) pediu a chave do carro para a vítima, mas ela virou e tentou tomar o revólver de suas mãos, momento em que lhe desferiu golpes com a coronha da arma, (j) acabou se desesperando e atirou na mulher, tendo mirado para acertar na perna, (k) também queria acertar as pernas de José, mas acabou acertando no abdômen, (l) o motivo do roubo era o pagamento de dívida de tráfico, (m) a arma de fogo era de sua namorada.

Conforme dito alhures, a autoria está igualmente demonstrada. As vítimas já haviam reconhecido o acusado em sede policial – ainda que por imagens –, e novamente identificaram o acusado como um dos indivíduos que os abordaram e cometeram os delitos ora imputados. Ainda, o próprio réu confessou espontaneamente a prática dos crimes, mesmo que parcialmente.

Portanto, a dinâmica dos fatos restou devidamente apurada: (a) Ryan, ora réu, juntamente com sua então namorada (Gabrielly da Silva), e um amigo (Marcos Henrique Guimarães Carvalho), se vincularam previamente para o cometimento de um roubo, (b) se deslocaram de Praia Grande até Mongaguá para encontrarem possíveis vítimas, permanecendo momentaneamente em um bar para observarem a movimentação na região, (c) visualizaram as vítimas José e Maria saindo de sua casa de veraneio, resolvendo subtraí-los, (d) Ryan, ora acusado, portava uma arma de fogo, tendo imobilizado momentaneamente a vítima José com um golpe mata-leão, que conseguiu se desvencilhar, momento em que Ryan deferiu-lhe diversos golpes com a coronha do revólver, causando sangramentos na vítima, (e) o comparsa Marcos tentou encontrar as chaves do carro de propriedade das vítimas, mas não se encontrava no contado do veículo, (f) Maria, ao se assustar com a situação vivenciada, saiu do veículo para socorrer seu marido, momento em que Ryan efetuou um disparo com a arma de fogo portada em sua coxa esquerda, causando-lhe lesão corporal de natureza grave (fls. 245/246), (g) novamente voltando-se para José, exigindo-lhe a entrega das chaves do carro, não sendo atendido, Ryan desferiu contra ele – José – um disparo de arma de fogo na região da fossa ilíaca direita do abdômen, com perigo de vida (fls. 243/244), na tentativa de matá-lo ou, ao menos, assumindo o risco, (h) o telefone celular da vítima José foi subtraído, (i) em razão de pessoas que se aproximaram ao

ouvirem os disparos de arma de fogo, os assaltantes empreenderam fuga, (j) o cometimento do crime patrimonial foi motivado pela dívida com traficantes, em razão do consumo de drogas pelos envolvidos, mas não pagas.

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente para considerar demonstrada a materialidade e autoria delitivas.

Quanto à tipicidade, o fato praticado preenche parcialmente as elementares do tipo penal imputado na denúncia. Mostra-se necessário, porém, a adequação típica da conduta praticada contra a vítima Maria da Conceição Uchôa, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Explico.

O acusado Ryan, juntamente com dois comparsas, visava a subtração patrimonial das vítimas, em especial o veículo Ford-Ranger 2017/2018 de placa GDW-9877, mas lograram êxito na inversão da posse somente de um aparelho celular de propriedade da vítima José. Durante a empreitada criminoso, a queima-roupa, Ryan disparou com a arma de fogo na região da perna da vítima Maria, não sendo hipótese de reconhecer o animus necandi da conduta. Ao que tudo indica, sua intenção era de ferir a vítima para que não reagisse e, considerando a distância em que efetuado o disparo, inviável reconhecer que o acusado visava alcançar o resultado morte de Maria.

Partindo-se da mesma premissa esposada, o animus necandi em relação a José é evidente. Também a queima-roupa, Ryan realizou um disparo com arma de fogo contra a vítima, mas em seu abdômen, região em que localizados órgãos vitais do ser humano. Constatou da perícia que "foi submetido a tratamento cirúrgico de emergência (laparotomia exploradora) devido a ferimento por arma de fogo no abdome (fossa ilíaca esquerda). Permaneceu internado por 3 dias. (...) Concluiu que o periciando apresenta lesões corporais de natureza grave pelo perigo de vida ocasionado por lesões internas que necessitaram pronta intervenção cirúrgica." (fls. 243/244).

Portanto, entendo que o acusado praticou dois delitos distintos: (a) latrocínio (art. 157, parágrafo 3º, inciso II, CP) contra José e, (b) roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (art. 157, parágrafo 3º, inciso I, CP) contra Maria.

Ambos os crimes foram praticados na forma tentada (art. 14, inciso II, CP), pois não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do autor, consistente na necessidade de fuga do local dos delitos quando da aproximação de transeuntes. Quanto à vítima Maria, embora o resultado "lesão corporal grave" foi consumado (fls. 245/246), não teve bens subtraídos; por outro lado, em relação a José, embora subtraído seu aparelho celular, o resultado morte não se consumou (fls. 243/244).

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (ratio cognoscendi) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que o agente é imputável e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Não foram, pois, comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, constata-se que foi praticada conduta típica e ilícita e por agente culpável, de modo que, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Constata-se que foram praticados dois delitos, em um mesmo contexto fático. A ação, por evidente, foi "dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos", fazendo incidir o comando normativo previsto na segunda parte do art. 70, Código Penal, consistente no concurso formal impróprio. Como resultado, as penas aplicam-se cumulativamente. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. CRIME PRATICADO CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIME DE RECURSO PROVIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. GARRUCHA.22. APREENSÃO LOGO APÓS A PRÁTICA DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. DELITO PRATICADO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. AGRAVO PROVIDO.

1. Não obstante configurado concurso formal impróprio, e não concurso material, quando praticado os crimes de roubo e latrocínio tentado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, inexiste reflexo na dosimetria da pena, por ser idêntica à regra do concurso material, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP.

2. Aplica-se o princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo e aos delitos contra o patrimônio ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexos de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do roubo e do latrocínio tentado. 3. Não incide a Súmula 7/STJ quando os fatos se encontram delimitados pelo acórdão recorrido, sendo necessária nova valoração jurídica da prova, e não reexame fático-probatório, uma vez que a conduta do réu se apresenta incontroversa.

4. Agravo regimental provido para redimensionar a pena."

(AgRg no AREsp n. 1.395.908/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019.)

Quanto a causas modificativas da pretensão punitiva, verifica-se que o acusado é tecnicamente primário (fls. 443/445). Embora não tenha confessado na íntegra a empreitada criminosa, buscando afastar qualificadora do resultado morte em seu interrogatório, entendo que os relatos trazidos pelo acusado foram suficientes para a formação da convicção deste Julgador e, inclusive, os elementos por ele suscitados integraram a fundamentação desta sentença condenatória. Portanto, necessária a consideração da atenuante prevista no art. 65, III, "d", Código Penal. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...)

4. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador.

5. Na espécie, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, o réu admitiu que manteve relação sexual com a ofendida, ainda que de forma consensual, o que contribuiu para a busca da verdade real, de modo que deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão.

(...)

8. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e conceder o habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, a fim de redimensionar a pena do paciente nos termos acima expostos."

(EDcl no AgRg no HC n. 753.304/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Verifica-se, ainda, a atenuante relativa à idade do autor do delito à época dos fatos, nos termos do art. 65, I, Código Penal. Nascido em 04 de julho de 2001 (fls. 439/442) e cometidos os crimes em 27 de junho de 2021, contava com 19 anos de idade.

Por outro lado, também existem agravantes a serem consideradas. Conforme confessado pelo próprio acusado, o crime foi cometido visando angariar fundos para o pagamento

de dívida com o tráfico de drogas. Ryan e sua então namorada, e corré Gabrielly, obtiveram grande quantidade de substâncias entorpecentes e as consumiram, mas não tinham dinheiro para pagar por elas. Em última análise, portanto, os graves crimes patrimoniais ora analisados foram cometidos para a aquisição de drogas, motivo este torpe, incidindo a agravante prevista no art. 61, II, "a", Código Penal.

Verifica-se que os crimes foram praticados mediante emboscada e outros meios que dificultou a defesa das vítimas. Os autores dos delitos se encontravam de tocaia a poucos metros da residência da vítima, aguardando o melhor momento para agirem. Quando da abordagem, a vítima José se encontrava agachado, de costas para a via pública, enquanto sua esposa, também vítima, Maria, estava dentro do carro – sem as chaves na ignição –, aguardando José trancar os cadeados do portão para partirem. Ou seja, aplicável no caso concreto a agravante descrita no art. 61, II, "c", Código Penal.

Ainda, presente a agravante objetiva positivada no art. 61, II, "h", Código Penal, pois a vítima José contava com 75 anos à época dos fatos, e a vítima Maria tinha 73 anos de idade (fls. 06).

Quanto às agravantes, foram reconhecidas duas de natureza objetiva (art. 61, II, "c" e "h", Código Penal) e uma de natureza subjetiva (art. 61, II, "a", Código Penal). Em relação às atenuantes, reconhecida uma de natureza objetiva (art. 65, I, Código Penal) e uma de natureza subjetiva (art. 65, III, "d", Código Penal). Diante deste cenário, cabível a compensação integral da agravante subjetiva (motivo fútil) com a atenuante subjetiva (confissão espontânea), assim como a compensação entre uma das agravantes objetivas (idade das vítimas à época dos crimes) com a atenuante objetiva (idade do autor à época dos crimes). Remanesce, portanto, para fins de dosimetria na segunda fase, a agravante relativa à emboscada e outros meios que dificultou a defesa das vítimas (art. 61, II, "c").

Por fim, não incidem causa de aumento da pena. Há, porém, a causa genérica de diminuição da pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP). Em razão das peculiaridades dos delitos praticados, serão analisadas em apartado.

A título de observação, consigno que as causas de aumento previstas nos parágrafos 2º, 2º-A e 2º-B do art. 157 do Código Penal não são aplicáveis às espécies qualificadas de roubo. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO § 2º DO ART. 157 DO CP À FIGURA PREVISTA NO § 3º DO REFERIDO DISPOSITIVO. CONJUGAÇÃO INVIÁVEL. LOCALIZAÇÃO TOPOLÓGICA E CONJUNÇÃO QUE CAUSARIA DESPROPORCIONALIDADE NA RESPOSTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO § 2º DO ART. 157 DO CP À FIGURA PREVISTA NO § 3º DO REFERIDO DISPOSITIVO. CONJUGAÇÃO INVIÁVEL. LOCALIZAÇÃO TOPOLÓGICA E CONJUNÇÃO QUE CAUSARIA DESPROPORCIONALIDADE NA RESPOSTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As qualificadoras e as majorantes se traduzem como circunstâncias que orbitam o tipo básico. Sob viés formal de exposição desses institutos no Código, são fixados novos limites mínimo e máximo de pena para os casos de qualificadoras, diversamente do que se dá em relação às majorantes, para as quais é prevista fração de aumento, que incidirá sobre o tipo básico e que deve ser observada na terceira fase de aplicação da reprimenda.

2. No tocante ao roubo, observa-se que foram elencadas, em vários incisos, diferentes situações que contemplam dados circunstanciais e especializantes, em detrimento da figura típica básica inserida no caput do art. 157 do CP. Infere-se que o legislador, em tais situações, optou por tratá-las como causas especiais de aumento de pena e, assim, ao invés de dotá-las de sanção própria, estabeleceu apenas uma fração de aumento sobre a pena do tipo fundamental.

3. Um dos argumentos mais usados para que não se permita o cúmulo das referidas majorantes com a figura prevista no § 3º do art. 157 do CP é sua localização normativa, vale dizer, após o dispositivo sobre as causas de aumento, dotando-o de pena própria. Se, de um lado, tal argumento, isoladamente, é insuficiente para justificar a impossibilidade de conjugação das majorantes com as qualificadoras, de outro lado, também não basta, para permitir essa conjugação, a assertiva de que todos os parágrafos devem ser interpretados em conjunto, porque todas as circunstâncias previstas no § 2º e no § 3º são apenas especializantes do tipo básico.

4. Para além da localização normativa dos dispositivos, é impositivo que se agregue outro argumento relevante, que acaba por impossibilitar essa conjugação de circunstâncias (conjunção do § 2º com o § 3º). Esse argumento diz respeito ao excesso de pena resultante dessa interpretação, que acaba por ocasionar graves violações do princípio de proporcionalidade, um dos pilares centrais da resposta punitiva ao crime.

5. O roubo, em sua forma simples, comina pena inicial de 4 anos de reclusão. Se incide alguma majorante, a reprimenda sobe para o patamar mínimo de 5 anos e 4 meses. Comparados esses parâmetros com a pena mínima prevista para o roubo seguido de lesão corporal grave, verifica-se um salto, passando a pena mínima em abstrato para 7 anos de reclusão. Na hipótese de resultado morte, a reprimenda inicial dispara para 20 anos de reclusão. Tomando-se em consideração que o roubo seguido de morte (latrocínio) se insere entre os crimes contra o patrimônio, fica evidente que a reprimenda cominada já comporta toda a censurabilidade possível da conduta, que não permite o acréscimo de mais circunstâncias, notadamente porque reproduz uma pena maior do que a que teoricamente pode ser atingida por um crime contra a vida, para o qual, em sua forma qualificada, a pena mínima é de 12 anos.

6. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 1.638.391/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI).

- Artigo 157, parágrafo 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, CP.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) mostra-se elevada, pois praticado o delito em concurso com outros dois indivíduos, tendo Ryan agido com a maior agressividade durante a empreitada criminosa, merecendo uma reprimenda estatal mais acentuada em relação aos seus comparsas. Quanto aos antecedentes, o acusado é tecnicamente primário e de bons antecedentes (fls. 443/445). Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Quanto às circunstâncias do crime, constato que foi praticado com o emprego de arma de fogo, em plena luz do dia (por volta das 13h10), acarretando disparos que colocaram em risco a incolumidade física da coletividade, razão pela qual deve ser valorada negativamente esta circunstância. Os motivos da infração penal, embora claramente torpes, pois visava ao pagamento de dívida com o tráfico de drogas, serão valorados na segunda fase. As consequências da infração penal são graves, pois a vítima José foi submetida a cirurgias, permaneceu internado por 08 dias e ainda sente uma espécie de formigamento no local do ferimento. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto aos critérios para a fixação da pena-base (CP, art. 59, II), tal atividade jurisdicional não está adstrita a etapas puramente aritméticas, com a estrita vinculação a bases de cálculo e frações de acréscimo obrigatórias, mas sim deve observar o princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI), o dever de fundamentação das decisões judiciais (CR/88, art. 93, IX) e o dever de isonomia (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º).



Logo, exige-se um juízo racionalmente fundamentado de coerência entre o intervalo abstratamente previsto entre a pena mínima e a pena máxima (premissa maior), a quantidade e natureza das circunstâncias judiciais avaliadas (premissa menor) e a exasperação da pena promovida (conclusão). Nesse sentido, por todos, cf. STJ, AgRg no AREsp 1.659.986/RS, Sexta Turma, DJe 11/03/2021. De todo modo, diante da inexistência de critério legal positivado, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o referencial básico de exasperação da pena mínima (base de cálculo) em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima por cada circunstância judicial negativa (fração de acréscimo): "a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo", admitida a aplicação de fração diversa "diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). No mesmo sentido: STJ, HC 605.628/SP, Quinta Turma, DJe 08/04/2021; AgRg no HC 548.785/RJ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020; HC 585.748/CE, Sexta Turma, DJe 10/02/2021. A corroborar tal critério, cf. ainda: TJSP; Apelação Criminal 1500855-04.2020.8.26.0583; 2ª Câmara de Direito Criminal; j. 31/05/2021; TJSP; Apelação Criminal 0000505-83.2018.8.26.0123; 3ª Câmara de Direito Criminal; j. 11/12/2020; TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0012086-82.2016.8.26.0635; 8ª Câmara de Direito Criminal; j. 28/02/2019; TJSP; Apelação Criminal 0004418-97.2015.8.26.0052; 6ª Câmara de Direito Criminal; j. 30/08/2018.

À luz de tal diretriz, no caso, ante a valoração das duas circunstâncias judiciais supra, acresce-se a pena mínima em 3/8 (três oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, a resultar na pena-base de 23 anos e 09 meses de reclusão, mais 139 dias-multa.

Na segunda fase, conforme fundamentação supra, incidem duas agravantes de natureza objetiva (art. 61, II, "c" e "h", Código Penal) e uma de natureza subjetiva (art. 61, II, "a", Código Penal). Quanto às agravantes, reconhecida uma de natureza objetiva (art. 65, I, Código Penal) e uma de natureza subjetiva (art. 65, III, "d", Código Penal). Remanesce, portanto, para fins de dosimetria na segunda fase, a agravante relativa à emboscada e outros meios que dificultou a defesa das vítimas (art. 61, II, "c"). Assim, fixo a pena provisória em 27 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, mais 164 dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento da pena. Há, porém, a causa genérica de diminuição da pena relativa à tentativa (art. 14, II, Código Penal), em patamar variável entre um a dois terços da pena. Conforme jurisprudência pacificada, o C. STJ "adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição."

O latrocínio é crime de natureza complexa, tutelando dois bens jurídicos, quais sejam, o patrimônio e a vida. No presente caso, embora o veículo automotor não foi subtraído, o aparelho celular de José teve a posse invertida em favor dos assaltantes, ocorrendo efetivamente a violação à esfera patrimonial da vítima. Quanto ao resultado morte, este não ocorreu, embora tenha José se submetido a cirurgias abdominais e permanecido por 08 dias em internação hospitalar. Portanto, mostra-se razoável a diminuição da pena em patamar intermediário do intervalo positivado, qual seja, em 2/5 da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 16 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, mais 96 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve

atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade, observando-se as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime fechado.

Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que foi decretada a prisão cautelar do acusado no curso da persecução penal. Contudo, o lapso não interfere na fixação do regime inicial, pois a fixação do regime mais gravoso se deu não apenas em razão do patamar da pena, mas também pelas circunstâncias judiciais negativas.

Ademais, o lapso de prisão cautelar no caso não deve interferir na fixação do regime, tendo em vista que não ultrapassa o lapso temporal exigido como requisito objetivo para a progressão de regime, determinado pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), e não há elementos nos autos que permitam a aferição do requisito subjetivo imposto para a concessão do aludido direito. A aferição do cabimento da progressão de regime deve, pois, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos autos da execução.

Quanto à fixação de valor mínimo a título de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), a ausência de pedido impede a sua fixação por força dos princípios da demanda, da adstrição e do contraditório.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

- Artigo 157, parágrafo 3º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, CP.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) mostra-se elevada, pois praticado o delito em concurso com outros dois indivíduos, tendo Ryan agido com a maior agressividade durante a empreitada criminosa, merecendo uma reprimenda estatal mais acentuada em relação aos seus comparsas. Quanto aos antecedentes, o acusado é tecnicamente primário e de bons antecedentes (fls. 443/445). Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Quanto às circunstâncias do crime, constato que foi praticado com o emprego de arma de fogo, em plena luz do dia (por volta das 13h10), acarretando disparos que colocaram em risco a incolumidade física da coletividade, razão pela qual deve ser valorada negativamente esta circunstância. Os motivos da infração penal, embora claramente torpes, pois visava ao pagamento de dívida com o tráfico de drogas, serão valorados na segunda fase. As consequências da infração penal são graves, pois a vítima Maria ostenta cicatriz no local do ferimento, apresenta sensação de queimadura na coxa e encontra-se psicologicamente abalada, não mais conseguindo frequentar sua casa em Mongaguá. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto aos critérios para a fixação da pena-base (CP, art. 59, II), tal atividade jurisdicional não está adstrita a etapas puramente aritméticas, com a estrita vinculação a bases de cálculo e frações de acréscimo obrigatórias, mas sim deve observar o princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI), o dever de fundamentação das decisões judiciais (CR/88, art. 93, IX) e o dever de isonomia (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º).

Logo, exige-se um juízo racionalmente fundamentado de coerência entre o intervalo abstratamente previsto entre a pena mínima e a pena máxima (premissa maior), a quantidade e natureza das circunstâncias judiciais avaliadas (premissa menor) e a exasperação da pena promovida (conclusão). Nesse sentido, por todos, cf. STJ, AgRg

no AREsp 1.659.986/RS, Sexta Turma, DJe 11/03/2021. De todo modo, diante da inexistência de critério legal positivado, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o referencial básico de exasperação da pena mínima (base de cálculo) em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima por cada circunstância judicial negativa (fração de acréscimo): "a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo", admitida a aplicação de fração diversa "diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). No mesmo sentido: STJ, HC 605.628/SP, Quinta Turma, DJe 08/04/2021; AgRg no HC 548.785/RJ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020; HC 585.748/CE, Sexta Turma, DJe 10/02/2021. A corroborar tal critério, cf. ainda: TJSP; Apelação Criminal 1500855-04.2020.8.26.0583; 2ª Câmara de Direito Criminal; j. 31/05/2021; TJSP; Apelação Criminal 0000505-83.2018.8.26.0123; 3ª Câmara de Direito Criminal; j. 11/12/2020; TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0012086-82.2016.8.26.0635; 8ª Câmara de Direito Criminal; j. 28/02/2019; TJSP; Apelação Criminal 0004418-97.2015.8.26.0052; 6ª Câmara de Direito Criminal; j. 30/08/2018.

À luz de tal diretriz, no caso, ante a valoração das duas circunstâncias judiciais supra, acresce-se a pena mínima em 3/8 (três oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, a resultar na pena-base de 11 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, mais 139 dias-multa.

Na segunda fase, conforme fundamentação supra, incidem duas agravantes de natureza objetiva (art. 61, II, "c" e "h", Código Penal) e uma de natureza subjetiva (art. 61, II, "a", Código Penal). Quanto às agravantes, reconhecida uma de natureza objetiva (art. 65, I, Código Penal) e uma de natureza subjetiva (art. 65, III, "d", Código Penal). Remanesce, portanto, para fins de dosimetria na segunda fase, a agravante relativa à emboscada e outros meios que dificultou a defesa das vítimas (art. 61, II, "c"). Assim, fixo a pena provisória em 12 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, mais 164 dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento da pena. Há, porém, a causa genérica de diminuição da pena relativa à tentativa (art. 14, II, Código Penal), em patamar variável entre um a dois terços da pena. Conforme jurisprudência pacificada, o C. STJ "adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição."

O roubo qualificado pela lesão corporal grave é crime de natureza complexa, tutelando dois bens jurídicos, quais sejam, o patrimônio e a incolumidade física. No presente caso, não foram subtraídos bens de Maria. Quanto ao resultado lesão corporal grave, restou plenamente comprovado nos autos. Portanto, mostra-se razoável a diminuição da pena em patamar intermediário do intervalo positivado, qual seja, em 2/5 da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 07 anos, 09 meses e 13 dias de reclusão, mais 96 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade, observando-se as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime fechado.

Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que foi decretada a prisão cautelar do acusado no curso da persecução penal. Contudo, o lapso não interfere na fixação do regime inicial, pois a fixação do regime mais gravoso se deu não apenas em razão do patamar da pena, mas também pelas circunstâncias judiciais negativas.

Ademais, o lapso de prisão cautelar no caso não deve interferir na fixação do regime, tendo em vista que não ultrapassa o lapso temporal exigido como requisito objetivo para a progressão de regime, determinado pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), e não há elementos nos autos que permitam a aferição do requisito subjetivo imposto para a concessão do aludido direito. A aferição do cabimento da progressão de regime deve, pois, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos autos da execução.

Quanto à fixação de valor mínimo a título de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), a ausência de pedido impede a sua fixação por força dos princípios da demanda, da adstrição e do contraditório.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Por fim, confirme fundamentação supra, foram praticados dois delitos, em um mesmo contexto fático. A ação, por evidente, foi “dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos”, fazendo incidir o comando normativo previsto na segunda parte do art. 70, Código Penal, consistente no concurso formal impróprio, cujo regramento consiste na soma das penas aplicadas. Portanto, resta fixada a pena do acusado em 24 anos, 04 meses e 28 dias de reclusão, mais 192 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia contra RYAN DE FRANÇA SILVA AGUIAR para CONDENÁ-LO (a) ao cumprimento, em regime inicial fechado, da privativa de liberdade consistente em 16 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 96 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), em razão da prática da infração penal descrita no artigo 157, parágrafo 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, (b) ao cumprimento, em regime inicial fechado, da privativa de liberdade consistente em 07 anos, 09 meses e 13 dias de reclusão, mais o pagamento de 96 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no artigo 157, parágrafo 3º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Em razão do concurso formal impróprio, e nos termos da segunda parte do artigo 70 do Código Penal, fica estabelecida a condenação final de Ryan de França Silva Aguiar em 24 anos, 04 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 192 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Quanto à manutenção da prisão cautelar, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, cumpre notar que as razões já esposadas para a sua decretação permanecem presentes. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado. Por tais razões, impõe-se a manutenção da prisão preventiva dos acusados. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma,

DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único).

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, com o trânsito em julgado, expeça-se certidão da sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 480, NSCGJ/SP.

Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Mongaguá, 21 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA